



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 127/15

בענין: מינצר אירינה
ארסני מינצר

ע"י ב"כ עו"ד רם סימיס ואח'
מרח' אחד העם 2, חיפה 31047
טל': 04-8620370, פקס: 04-8627396

הנתבעים

נ ג ד

1. איתמר אשכולות
2. שרה אשכולות

ע"י ב"כ עו"ד שמעון צח ואח'
מרח' חורי 2, מגדל הנביאים, קומה 8, חיפה
טל': 04-8643264, פקס: 04-8645826

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. עניינה של התביעה הוא בניה שבנו הנתבעים בחלקה הרשומה בבעלות משותפת של הצדדים להליך, על פי הנטען, בניגוד להסכם שיתוף שנחתם בין הצדדים להליך. התובעים עתרו למתן צו עשה שיורה על הריסתן של עבודות הבניה שלהלן: הריסת יחידת הדיור בצד המערבי של המבנה ואיטום החלל ביסוד המבנה; ביטול יחידת דיור נוספת שנבנתה בצד המזרחי; הריסת קיר ודלת אשר מונעים יציאה מהמקלט של התובעים; פירוק קירוי שנבנה בצד המערבי; איטום השטח שנחפר תחת מחסן הנתבעים; פירוק המדרגות שנבנו בשטח משותף המובילות למחסן הנתבעים. בנוסף עתרו התובעים למתן צו עשה שיורה לנתבעים: להקצות שטח לפחי אשפה חלף השטח שיועד לכך; לפנות מיטלטלין מהגג המשותף; להחזיר את תאורת החשמל שהייתה קיימת במדרגות החיצוניות; להעביר את שעוני המים המשמשים אותם לשטח הפרטי, ולאסור על אחסון מיטלטלין בשטחם בצמוד לרחוב.

רקע ועובדות שאינן במחלוקת-

2. הבית מושא ההליך הוא בית דו משפחתי המצוי ברח' האג 8, חיפה, מזוהה כחלקה 218 בגוש 12263, (להלן: "הבית").

3. התובעים רכשו דירתם מאמו של נתבע מס' 1 (להלן: "רחל"). בין רחל לבין נתבע מס' 1 (להלן: "הנתבע") נחתם ביום 26.5.10 הסכם שיתוף בו חולקו זכויות

החזקה והשימוש במקרקעין (להלן: "ההסכם"). ההסכם הוגש וסומן ת/2. להסכם צורף תשריט של המודד קובי זייד המדגים את חלוקת השטח בין הצדדים (להלן: "התשריט"). התשריט הוגש וסומן ת/3.

4. חשובים לציטוט מההסכם הסעיפים הבאים:

2" ג. מוסכם ומוצהר ע"י הצדדים, כי כל צד ו/או חליפיו יהא רשאי לנהוג בחלקו במגרש שהוקנה לו ויוחד לו עפ"י הסכם השיתוף וחווה המכר, מנהג בעלים, לפי שיקול דעתו ובכפוף להוראות הסכם זה ולכל דין.

3 א. בכפוף להוראות הסכם זה ולכל דין, יוכל כל אחד מן הצדדים לעשות במגרשו ובזכויותיו עפ"י הסכם זה כל פעולה משפטית וכל עסקה במקרקעין, כפי שבעלים של מקרקעין רשאי לעשות בהם, ובכלל זה למכרו, להחכירו, לתיתו במתנה, להורישו, לשעבדו, למשכנו ולחלקו בכל צורה שהיא, כפי שימצא לנכון ובתנאים שימצא לנכון, לפי ראות עיניו ומבלי להזדקק להסכמה כלשהי ממשנהו.

4 א. מוסכם בין הצדדים, כי זכויות הבניה במקרקעין, בין הקיימות כיום עפ"י כל ת.ב.ע. מאושרת ובין שיוקנו בעתיד, אם יוקנו עפ"י כל דין, וכן כל הקלה אפשרית במקרקעין ו/או הנובעת מהמקרקעין יחולקו בין הצדדים בהתאם ליחס שבין שטח מגרשו של כל אחד לבין שטחו הכולל של המקרקעין.

ד. בכפוף להוראות הסכם זה, ניתנה ו/או ניתנת לכל אחד מן הצדדים הזכות לבצע במגרשו כל פעולת בניה, הריסה, נטיעה, חפירה, סלילה וכדומה, והכל בהתאם לדיני התכנון והבניה ולכל דין אחר המסדיר פעולות מסוג זה..."

ו. שום צד לא יבצע במגרשו בניה אשר עלולה לפגוע במגרש משנהו, ו/או לסכל ו/או להפריע ו/או למנוע את משנהו מלהשתמש שימוש מלא במגרשו. צד אשר פעל בניגוד לס' קטן זה, יפעל באופן מיידי לתיקון ו/או להסרה ו/או הפרעה ו/או מטרד שנגרמו למשנהו. (הדגשות שלי י.ל.).

5. בסעיף 8 להסכם נקבע שעם רישום הבית כבית משותף יוטמעו הוראות ההסכם בתקנון המוסכם שיירשם. ההסכם והתשריט לא נרשמו בלשכת רישום המקרקעין, והבית טרם נרשם כבית משותף.

6. ביום 26.5.13 הגישה הוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה כתב אישום (מתוקן) כנגד הנתבע בת.פ. מס' 270/13, בו נכללו בין היתר העובדות הבאות: בניית יחידה בצד המערבי של המבנה, הפיכת מחסן בחזית המזרחית של המבנה לשטח מגורים, בניית קיר בטון ובלוקים הכוללת דלת כניסה בחזית המזרחית בקומת הקרקע, בניית מחסן הכולל פתחים מתחת לחניה.

7. בדיון שהתקיים בבית המשפט לעניינים מקומיים בחיפה ביום 18.5.15 בתיק, הודה הנתבע בכל עובדות כתב האישום שפורטו לעיל, והורשע בכל העבירות המיוחסות לו. כתב האישום וגזר הדין הוגשו וסומנו ת/15.

טענות התביעה-

8. הנתבעים ביצעו בחלקה בניה מסוגים שונים ללא שקיבלו לכך הסכמת התובעים וללא שהתקבל להן היתר בניה. יש בבניה כדי לגרום לנתבעים פגיעה.
9. בצידה המערבי של החלקה בנו הנתבעים מתחת לדירתם יחידת דיור שלמה ונפרדת. היחידה נבנתה בשטח המהווה רכוש משותף. היחידה נבנתה ללא שהנתבעים קיבלו לכך את הסכמת התובעים והיתר בניה.
10. בצידה המזרחי של החלקה הסבו הנתבעים מחסן ליחידת דיור נפרדת ללא הסכמות וללא היתר בניה.
11. הנתבעים חפרו מתחת למחסן שלהם והגדילו את עומקו של המחסן ללא הסכמות והיתר בניה.
12. הנתבעים חסמו את פח המילוט ממקלט התובעים ע"י בניית קיר.
13. מקצת עבודות הבנייה בוצעו בשטחים שאינם שייכים לנתבעים ועבודות אחרות אמנם בוצעו בשטחים שבחזקת הנתבעים אך הן נעדרות היתר בניה כדין.

טענות ההגנה-

14. מרבית הסעדים להם עותרים התובעים אינם בסמכות המפקח על רישום מקרקעין.
15. המדרגות והקיר שהתובעים עותרים להריסתם נבנו במימון משותף של שני הצדדים להליך, ומשכך ברי כי ניתנה הסכמת התובעים לעבודות אלו.
16. התובעים עותרים לצו שיורה על העתקת מוני המים של הנתבעים משטח משותף לשטח הפרטי, בה בעת שמוני המים שלהם מצויים אף הם בשטח המשותף.
17. התובעים בעצמם בנו תוספת לחניה שלהם ללא היתר בניה. אמנם זו קיבלה בשלב מאוחר יותר לגליזציה, אך אין בכך כדי להפחית מחוסר תום ליבם של התובעים אשר תוקפים כיום בנייה שביצע הנתבע בטענה שהיא נעדרת היתר בניה.
18. יש לדחות עתירתם של התובעים להסרתם של מדחסי מזגנים, קולטים וכו' שהתקינו הנתבעים על הגג המשותף לפני שנים רבות, שעה שהם בעצמם התקינו מתקנים דומים על הגג.

19. הבניה אותה מבקשים התובעים להרוס הייתה קיימת במועד בו הם רכשו את דירתם, והם הצהירו בהסכם המכר כי ראו את הבית ואת החלקה ואין להם כל טענות לגבי הקיים.

ההליכים בתיק-

20. בדיון שהתקיים ביום 11.5.15 נמחקו מבין הסעדים המבוקשים בכתב התביעה הסעדים הבאים: הריסת יחידת הדיור המערבית, איסור שימוש בשטח הצמדה לצרכי אחסון פסולת או כל שימוש החורג ממטרות השימוש של אותו שטח, הריסת הקונסטרוקציה הדו קומתית מעץ בהצמדת הנתבעים.

21. ביום 13.7.15 מונה על ידי כמומחה מוסכם מר אליאס קויפמן, מודד מוסמך (להלן: "המומחה"), המומחה התבקש לבדוק האם הסעדים שהתבקשו בכתב התביעה מתייחסים לשטחים אשר עפ"י הסכם השיתוף והתשריט צמודים לנתבעים או מהווים רכוש משותף. המומחה הגיש את חוות דעתו לתיק ממנה עלה כי כל עבודות הבניה שביצעו הנתבעים נעשו בשטחי יחידתם או הצמודותיהם עפ"י הסכם השיתוף והתשריט. סייג לאמור הן המדרגות המובילות למחסן הנתבעים אשר כ-50 ס"מ מהם נמצאו חורגים לשטח המשותף.

22. בדיון שהתקיים ביום 12.10.15 ביקשו התובעים לחזור בהם ממחיקת הסעד האמור בסעיף 23 א' לכתב התביעה, קרי, להשיב אל בין הסעדים המבוקשים את הריסת היחידה המערבית. הבקשה התקבלה ובהחלטה שניתנה על ידי נקבע כי במסגרת הראיות בתיק תידון גם הבניה שנעשתה ע"י הנתבעים בקרקע המצויה מתחת לדירתם או מתחת למחסן שלהם.

23. ביום 2.12.15 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם, על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען, וביום 21.7.16 קיימתי ביקור חוזר במקום. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:

(א) בצידה הצפוני של החלקה קיימת גישה ברכב וברגל אל החלקה מרח' האג.

(ב) 2 גרמי מדרגות מובילים מהרחוב אל הבית. האחד, מצדו המזרחי של הבית, שם מצויה כניסה לדירות הצדדים להליך, והשני מצדו המערבי של הבית. גרם זה מוביל אל החצר הצמודה לנתבעים ואל היחידה המערבית מושא ההליך.

(ג) בכניסה המזרחית לדירת הנתבעים קיים שטח, שאמנם נראה כי הוא משמש את הנתבעים לצרכי אחסון, אך הוא מחובר לדירת הנתבעים ומהווה את המשכה הטבעי של היחידה.

(ד) עוד בצידה המזרחי של החלקה, ממערב לגרם המדרגות המוביל לדירות הצדדים להליך, נבנה קיר עם דלת. היציאה מחלון המילוט של מקלט התובעים מובילה אל אותה הדלת. דלת זו ננעלת באמצעות מפתח מסוג "פרפר" המחובר

באופן קבוע לאותה הדלת בצד הפונה לכיוון חלון המילוט. בעת חירום ניתן לצאת מחלון המילוט ולפתוח את אותה הדלת ללא כל קושי. בין חלון המילוט לבין הדלת הציבו הנתבעים מיטלטלין אשר חוסמים או מקשים על המילוט. מעל שטח הצמדה זה בנו הנתבעים קונסטרוקציית עץ לקירוי השטח.

(ה) בצידה הצפון מזרחי של החלקה קיימת דרך סלולה המובילה אל חניית התובעים. מערבית לאותה הדרך קיים מחסן המשמש את הנתבעים. מובילות אליו 2 מדרגות. לא מצאתי כי מדרגות אלו מהווה הפרעה של ממש או מקשות על ההגעה באמצעות רכב או בכלל לחנייה.

(ו) בחלקה הצפוני של החלקה מצוי מחסן המשמש את הנתבעים. תחת אותו מחסן נחפר שטח באופן שנוספו תחתיו גרם מדרגות וכמחצית קומה נוספת. למחסן זה קיימים דלת כניסה ו- 2 פתחים לכיוון דרום.

(ז) בצידה המערבי של החלקה, במפלס קומת המרתף, קיימת יחידה המכילה: חדר שינה, חדר ארונות וחדר רחצה. ליחידה זו קיימת כניסה נפרדת והיא נחזית להיות בנויה מתחת לדירת הנתבעים.

(ח) במועד הביקור הופניתי אל דברים נוספים במקום אשר, כפי שיפורט להלן, מצאתי כי נזנחו במסגרת ההליך ומשכך אינני מוצאת לפרטם.

24. ביום 30.12.16, ביום 24.2.16 וביום 4.5.16 התקיימו דיוני הוכחות בתיק במסגרתם העידו מטעם התביעה התובע ומר איליה ספקטור, מפקח על הבניה בעיריית חיפה. מטעם ההגנה העידו מר חאלד ואדי, קבלן מטעם הנתבעים והנתבע בעצמו. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב וכעת נותר לי להכריע במחלוקת.

דיון והכרעה-

25. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה, הכל כפי שיפורט להלן.

סמכות עניינית-

26. הנתבעים טענו כי כמפקחת על רישום מקרקעין נעדרת אני סמכות לדון בתביעה, היות ועניינה בנייה בלתי חוקית שבנו הנתבעים בחלקה. לדידם, סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין אינה כוללת סמכות לדון בעבירות על חוק התכנון והבניה.

27. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין קבועה בסעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") אשר קובע כדלהלן:

72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה),

התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 221 ו-227 לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר."

28. אכן, סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין אינה כוללת סמכות לדון בעבירות על פי חוק התכנון והבניה. ואולם, בהתאם להוראת סעיף 72(א) לעיל קיימת למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בזכויות או חובות הנובעות מהתקנון החל על הבית. סעיף 77ב בפרק ו'1 לחוק המקרקעין שעניינו: בתים שאינם רשומים כבתים משותפים החיל גם על בתים שטרם נרשמו כבתים משותפים את סעיף 72 לחוק המקרקעין בו נקבעה סמכות המפקח על רישום מקרקעין.

29. זאת ועוד, בסעיף 77ג. לחוק המקרקעין נקבע כי על בית שטרם נרשם כבית משותף יחול התקנון המצוי שבתוספת.

30. בסעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת, נאסר על בעל דירה לבצע בדירתו או ברכוש המשותף שינויים אשר עשויים לסכן את הבית/הדירות, לשנות את ערכן או לפגוע בדירה אחרת, ללא שהקדים וקיבל לכך הסכמות של בעל הדירה האחרת/האסיפה הכללית, לפי העניין.

31. בנוסף, עד לתיקון 18 לחוק המקרקעין כל בנייה ברכוש המשותף הייתה טעונה הסכמה של 100% מבעלי הדירות בבית. משתוקן חוק המקרקעין, והוסף לו סעיף 71ב(א) הרי שכל אימת שעסקין בבנייה הרחבת דירה, טעונה הבניה הסכמה ברוב של 3/4 מבעלי הדירות שצמודים להם 2/3 מהרכוש המשותף, ובהינתן שמדובר בבנית ממ"ד די בהסכמה של 60% מבעלי הדירות בבית. כך או אחרת, אין מחלוקת כי רוב זה לא קיים לנתבעים.

32. היות ועסקין בשינויים שביצעו הנתבעים בדירתם או ברכוש המשותף קיימת לי הסמכות העניינית לדון בתביעה מכוחה של הוראת סעיף 2 לתקנון המצוי.

33. במסגרת תביעה זו אדרש להסכמות הנדרשות לבניה בפן הקנייני, ולשאלה האם נתנו לנתבעים.

הסכם השיתוף והתשריט-

34. אין חולק כי בין הנתבע לבין רחל, היא הבעלים הקודם בדירת התובעים, נחתמו ההסכם והתשריט. מה מעמדו של ההסכם?

35. סעיף 30 לחוק המקרקעין קובע מהו הסכם שיתוף:

“(א) הסכם בין שותפים בדבר ניהול המקרקעין המשותפים והשימוש בהם ובדבר זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למקרקעין (להלן-הסכם שיתוף) ניתן לרישום, ומשנרשם, כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה שותף לאחר מכן וכל אדם אחר.”

36. הסכם שיתוף הינו, למעשה, הסדר חוזי בין הצדדים החתומים עליו, אשר משעה שנרשם עולה הוא לדרגת קניין – יוצר תוצאות מיוחדות באשר להיקף ולמשמעות ההכפפה של זרים, ולמעשה משפיע על כולי עלמא. ראו בעניין דבריו של פרופ' מ. דויטש, קניין, כרך א' בעמ' 559.

37. אמנם בענייננו הסכם השיתוף נחתם בין הנתבע לבין רחל והוא לא נרשם בפנקס המקרקעין, אך התובע אישר בעדותו כי בשלב החתימה על הסכם הרכישה של הדירה חתמו הוא ואשתו גם על הסכם השיתוף ועל התשריט, ראו עדותו בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 11-14. משכך, ועל אף שההסכם לא נרשם, מרגע שהנתבע ואשתו חתמו עליו יש לראותו כהסדר חוזי החל ומחייב את הצדדים להליך.

38. הנתבעים טוענים כי לאור הוראות ההסכם והתשריט שצורף לו הם אינם נדרשים להקדים ולקבל הסכמותיהם של התובעים לעבודות הבניה שביצעו, וזאת מהטעם שהסכם השיתוף שנחתם בין הצדדים פטר מהצורך בקבלת הסכמות.

39. עיון בהסכם השיתוף, מלמד כי הצדדים נתנו האחד למשנהו זכות רחבה ביותר לביצוע שינויים או בנייה בבית, **“כל צד... בחלקו במגרש”** לרבות: בניה, הריסה חלוקה של היחידה ועוד, הכל בכפוף לכך שהבניה תהא **“בניה בהתאם לדיני התכנון והבניה”**.

40. הפועל היוצא הוא שנדרשת אני לבחון לגבי כל אחד מרכיבי הבניה שנתבעו האם אותה הבניה נעשתה בשטח שהוא **“חלקו במגרש”** של הבונה, והאם התקבל לאותה הבניה היתר בניה, שזהו תנאי בלתו אין בהסכם השיתוף.

41. כל רכיב בנייה שיתקיימו לגביו נתונים אלו ניתן יהיה לראות את התובעים כמסכימים לאותה הבניה מכוחו של הסכם השיתוף. לעומת זאת, כל רכיב בנייה

שימצא כי נעשה בשטח שאינו חלקו של הבונה, או שהוא נעדר היתר בנייה לא ניתן יהיה לראות אותו כמי שחל לגביו ההסכם.

42. כאן המקום לציין כי בתשריט סומנו היחידה וההצמדות שבבעלות התובעים במספר 1 בצבע ירוק, והיחידה וההצמדות שבבעלות הנתבעים סומנו במספר 2 בצבע אדום

היחידה המערבית-

43. אקדים ואציין כי המומחה לא התבקש להתייחס בחוות דעתו ליחידה זו הואיל ובשלב מינויו נמחק סעד זה מבין הסעדים להם עתרו התובעים, והוא הושב רק בשלב מאוחר יותר. יחד עם זאת, העובדה שחוות הדעת לא התייחסה ליחידה זו אין בה לטעמי כדי להעלות או להוריד, מהטעם שממילא יחידה זו נבנתה בשטח המצוי מתחת לדירת הנתבעים, והשאלה האם שטח זה שייך לנתבעים, אם לאו, היא שאלה משפטית שאינה בתחום סמכותו של המומחה.

44. לגופו של ענין, התובע העיד כי נכנס לגור בבית ביום 22.7.10, וכי באותו מועד היו הנתבעים בעיצומן של העבודות לבנית היחידה המערבית (ראו עדותו בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 16-34). התובע טען כי יחידה זו פולשת אל השטח מתחת לדירתו. כשנשאל התובע על מה הוא מבסס את טענתו בנוגע לפלישה השיב: **"אני סבור כך"**. לא הובאה כל ראיה לטענה זו אשר לא הייתה חד משמעית אלא בגדר השערה בלבד, ראו עדותו בעמ' 28 לפרוטוקול שורות 31-35.

45. מנגד, הנתבע העיד כי יחידה זו נבנתה כבר בשנת 1995. לראיה צירף את תוכנית נ/13 משנת 1995 בה מודגם שטח יחידה זו בתוכנית קומת הקרקע. תוכנית זו נושאת חותמות הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה וכן חותמת כלשהי **"נתאשר"**.

46. על אף הגשתה של תוכנית נ/13, אשר לכאורה מדגימה את היחידה, לא שוכנעתי כי יחידה זו קיימת כבר משנת 1995, ולא שוכנעתי כי התקבל לגביה היתר בניה, וזאת משני טעמים: **האחד**, להסכם השיתוף שנחתם בשנת 2010 בין הנתבע לבין רחל צורף תשריט שהיווה חלק בלתי נפרד מההסכם. בתשריט שהוכן לבקשתם של הנתבע ושל רחל לא מופיעה היחידה המערבית. לו יחידה זו הייתה קיימת ובנויה עפ"י היתר בניה חזקה על הנתבע כי היה דואג לכך שיחידה זו תופיע בתשריט זה. **השני**, בכתב האישום שהוגש כנגד הנתבע בשנת 2015 מפורטת בסעיף 1א. לעובדות כתב האישום העובדה הבאה: **"בחזית המערבית במפלס המחסנים מתחת לחדר מגורים בנה יחידת דיור בשטח של כ-35 מ"ר..."**. בעובדה זו מתוארת היחידה המערבית. הנתבע הודה בעובדות המיוחסות לו, לרבות בעובדה שבנה יחידה זו ללא היתר, והורשע. חזקה על הנתבע שלא היה מודה בעובדה זו של כתב האישום לו היה בידיו היתר בנייה ליחידה זו.

47. זאת ועוד, בהסכם השיתוף הקנו הצדדים, כל צד למשנהו, אפשרויות שימוש, חזקה, בניה הריסה וכיוב' רחבות ביותר, ובתנאי שכל צד מבצען "בחלקו במגרש". בהואיל השני להסכם השיתוף הסכימו הצדדים כי חלוקת השטחים ביניהם נקבעת בהתאם למודגם בתשריט. וכך נקבע בהסכם: **"הואיל והם מסכימים ומאשרים שהחלקה, כולל הבניינים, השטחים המשותפים, המחסנים, והגינות, מחולקת ביניהם על פי המפורט בתשריט המודד המוסמך קובי זייד המאושר בידי עו"ד יורם נאומן ושהעתק צילום ממנו מצ"ב."** (תשריט ת/3 לעיל). עניינו הרואות כי הצדדים ביקשו ליתן לתשריט ולחלוקת השטחים שבו תוקף מחייב.

48. מעיון בהסכם השיתוף ובתשריט שצורף לו עולה כי היחידה המערבית לא מודגמת בו והיא גם לא מצויה בשטח שהוצמד לנתבעים.

49. על אף זאת טוענים הנתבעים כי היות והיחידה נבנתה בשטח המצוי מתחת לדירתם הרי שמדובר בשטח שבבעלותם מכוח הוראת סעיף 11 לחוק המקרקעין הקובעת כי: **"הבעלות בשטח של קרקע מתפשטת בכל העומק שמתחת לשטח הקרקע, בכפוף לדינים בדבר מים, נפט, מכרות, מחצבים וכיוצא באלה, והיא מתפשטת בחלל הרום שמעליו..."**.

50. לא מצאתי לקבל טענה זו. מעיון בתשריט עולה כי היחידה נבנתה בשטח שאינו מצוי "בחלקו במגרש" של הנתבע כפי הגדרתו בהסכם השיתוף, ואפרט-

51. החלקה מושא ההליך בנויה בקרקע משופעת הכוללת מפלסי קרקע שונים. בתשריט הודגמו בכל מפלס ומפלס השטחים שבבעלות כל אחד מהצדדים. מעיון בתשריט עולה כי הצדדים לא הצמידו האחד למשנהו את השטחים כשהם כוללים את כל העומק שמתחת לשטח היחידה ואת כל חלל הרום שמעליו (כפי הוראת סעיף 11 לחוק המקרקעין), אלא את מפלס ההצמדה בלבד.

52. חיזוק לעמדתי זו ניתן לראות בתשריט בהצמדות הבאות: השטח המצוי מעל לדירה של הנתבעים, על אף היותו ברום השטח שבבעלותם, סומן בתשריט כשטח המהווה צמידות משוטפת לשני הצדדים, הצמדה טז'. חניה ד' הוצמדה לדירת התובעים על אף שהיא מצויה מעל דירת הנתבעים. המחסן המערבי של הנתבעים מצוי מתחת למרפסת של התובעים, וכן ראו המחסן הצפוני של הנתבע המצוי מתחת לשטח שמהווה צמידות משותפת, ועוד. הבית מושא ההליך נבנה במספר מפלסים ומעל/מתחת שטח דירה של האחד מצויה, כאמור, הצמדה של משנהו, באופן שאינו מותיר ספק כי כוונת הצדדים הייתה ששטח הבעלות/הצמדה יסתיים במפלס התקרה או הרצפה שמעליה/מתחתיה, לא כל שכן במקום בו לא צוין מפורשות כי ההצמדה היא לרבות השטח מתחתיה/מעליה. וראו בעניין את הדברים שנאמרו בספרו של א. איזנשטיין, **בתים משותפים**, חלק שלישי בעמ' 127, כי הבעלות על שטח הצמדה אינה מתפשטת לגובה ולעומק, ויש לראות ברכוש הצמוד רק את מה שהוצמד מפורשות.

53. היחידה המערבית אמנם נבנתה בעומק הקרקע מתחת לשטח דירת הנתבעים, אך היות ובתשריט שטח זה לא הוצמד באופן מפורש לנתבעים מוצאת אני לקבוע כי שטח זה אינו בבעלותם אלא מהווה רכוש משותף. לאור זאת, ובהינתן שהנתבע בנה יחידה זו בשטח שאינו "חלקו במגרש", אלא מהווה שטח משותף, לא מצאתי להחיל עליו את הוראות הסכם השיתוף, הפטרות מהצורך בקבלת הסכמות הצד השני בהינתן היתר בניה. היות ועל היחידה לא חל הסכם השיתוף יש להחיל עליה את הוראות סעיף 62 (א) לחוק המקרקעין וסעיף 2(א) לתקנון המצוי ולפיהן נדרשת הסכמת התובעים לבנייתה.

54. לאור זאת, גם אם יקבלו הנתבעים היתר בנייה ליחידה זו במסגרת בקשת הלגליזציה שהגישו, לא יהיה בכך כדי ליתר את הצורך בהסכמת התובעים. ויפים לעניין זה דבריו של פרופ' דויטש, קנין, כרך א' בעמ' 695 :

"אין צורך להרחיב, כי זכות הבניה מבחינת דיני הקניין מצויה במישור אחד, וקיומו של היתר בניה מהוועדה המקומית, היא עניין למישור אחר. קיומו של היתר בניה אינו מצביע על כך שהבניה היא חוקית, אלא אך ורק על כך, כי היא חוקית מבחינת דיני התכנון והבניה. עדיין אין מניעה כלשהי לתקיפה של הבניה על פי דיני הקניין (נזיקין) לפי הכללים הרגילים. רשויות התכנון אינן בודקות את התקינות של הבניה מן הצד של זכויות הקניין..."

55. היות והתובעים והנתבעים הם הבעלים היחידים בחלקה מושא ההליך, הרי שלאור התנגדותם של התובעים לבניה, אין ולא יכולה לעמוד לנתבעים הסכמה לבניה ברוב הדרוש.

56. למעלה מהדרוש אציין כי היות ויחידה זו נבנתה ברכוש המשותף ללא קבלת הסכמה, הרי שמדובר בהסגת גבול במקרקעין, והיות והסגת גבול היא עילה המתחדשת מיום ליום ואינה מתיישנת, לא מצאתי כי קיימת משמעות למועד בו נחפרה היחידה על ידי הנתבעים. וראו בעניין ע"א 47/68 פ"ד כג(2) 52 וע"א זמיר נ' כימיכלים ופוספטים בע"מ פ"ד לז(3) 122.

57. לאור האמור מורה אני לנתבעים, ביחד ולחוד, להרוס את היחידה המערבית ולפעול לאיטום השטח בו נחפרה.

58. על מנת לאפשר הוצאת היתר בנייה להריסת היחידה, ועל מנת שיהיה די והותר זמן לצורך קבלת ליווי הנדסי לפעולות ההריסה והאיטום קוצבת אני פרק זמן של שנה לצורך יישום החלטתי זו.

היחידה המזרחית-

59. התובע העיד כי הנתבעים הסבו מחסן שלהם המצוי בצדה המזרחי של החלקה ליחידת דיור נוספת, ראו עדותו בעמ' 10 לפרוטוקול שורות 18-22.

60. בביקור במקום לא נמצאו עדויות לקיומה של יחידה נפרדת במיקום האמור אך ניכר שהשטח האמור מהווה חלק אינטגרלי מדירת הנתבעים.
61. בנוסף, עיון בהסכם השיתוף, מלמד כי הצדדים נתנו האחד למשנהו זכות רחבה ביותר לביצוע שינויים או בנייה כל אחד בחלקו במגרש. זכות זו כוללת אפשרות: בניה, הריסה חלוקה של היחידה ועוד, הכל בכפוף לכל דין.
62. מעיון בתשריט עולה כי שטח המחסן האמור מודגם בו כשטח השייך לנתבע ולכן מדובר בשטח שהוא "חלקו במגרש" של הנתבע. כשהתבקש התובע לסמן את היחידה האמורה בתשריט סימן אותה בתשריט במפלס קומת הקרקע בסימון X. (ראו עדותו בעמ' 11 לפרוטוקול שורות 41-33).
63. אמנם בתשריט השטח המסומן ב-X מופיע כחלק מדירת הנתבעים, תת חלקה מס' 2 ולא כמחסן (וראו לשם ההשוואה צורת הסימון של 4 מחסנים בקומת המרתף בתשריט), אך טוענים התובעים כי עפ"י היתר הבניה שטח זה אמור לשמש כמחסן והנתבע הסב אותו בניגוד להיתר הבניה לשטח מגורים.
64. לטענתם, היות ולא קיים בידי הנתבע היתר בנייה המאפשר הסבתו של שטח זה לשטח מגורים/יחידה, יש להורות לו לבטל יחידת מגורים זו ולהחזיר השטח לשימוש כמחסן.
65. מעדות מר ספקטור, מפקח בעיריית חיפה, עלה כי לפי תוכנית היתר הבניה שטח זה אמור לשמש כמחסן, ראו עדותו בעמ' 20 לפרוטוקול שורות 4-1 וכן את עדותו בעמ' 19 לפרוטוקול שורות 28-26. עוד עלה מעדותו כי הנתבעים הגישו בקשה לגליזציה לכל עבירות הבניה שיוחסו להם לרבות להסבת המחסן למגורים.
66. גם כתב האישום וגזר הדין תומכים באמור, ראו סעיף 1ב. לכתב האישום המתוקן, מוצג ת/15, שם מפורטת העובדה הבאה: "בחזית המזרחית במפלס קומת הקרקע בצמוד למקלט, הפך מחסן בשטח של כ-9 מ"ר לחדר מגורים". הנתבע הודה, כאמור, בעובדות כתב האישום, ואף הגיש בקשת לגליזציה לעבירות הבניה.
67. הפועל היוצא הוא שככל שהנתבעים יקבלו היתר בנייה להסבת המחסן למגורים הרי שהפיקתו ממחסן למגורים תעלה בקנה אחד עם הוראות הסכם השיתוף.
68. בפרק "סוף דבר" יפורטו הוראות ביצוע בעניין.
- הקיר שנבנה בסמוך למקלט וקונסטרוקציית העץ מעליו-
69. לטענת התובעים בנו הנתבעים בשטח הצמוד להם קיר אשר מונע אפשרות מילוט מהמקלט שבבעלותם, וכן בנו מעל קיר זה קונסטרוקציית עץ. הנתבעים

לא הכחישו טענה זו אלא טענו כי מדובר על בנייה בשטח שבבעלותם, שמותרת עפ"י הסכם השיתוף, וכי הקיר האמור אינו מונע מעבר דרכו בעתות חירום.

70. קיר זה מופיע אף הוא בין העובדות המפורטות בכתב האישום לגביהן הורשע הנתבע. בסעיף ג1. לכתב האישום נכתב: "בחזית המזרחית ובמקביל לה במפלס קומת הקרקע, בנה קיר בטון ובלוקים באורך של 4.7 מ' בגובה של כ-2.3 מ' בין קירות קיימים. בקיר פתח פתח לדלת והרכיב דלת." קירוי העץ מפורט בסעיף ד1. לכתב האישום: "מעל הקיר הנזכר בסי' ג' לעיל והקירות הקיימים בנה קונסטרוקצייה מעץ במידות של כ-4.8 מ' X 2 מ'". לאור כתב האישום ברי כי בניית הקיר נעשתה ללא היתר.

71. היות ואין חולק כי הקיר וכן הקונסטרוקצייה שנבנתה מעליו מצויים בשטח שצמוד לנתבעים, הרי שלאור הוראות הסכם השיתוף, אם יינתן היתר בנייה לאמור יהיה בכך כדי להכשירם.

72. היות וקיר זה נבנה בסמיכות לפתח המילוט ממקלט התובעים, ברי כי זכותם זו של הנתבעים לבניית הקיר כפופה לכך שלא יהיה בבנייה כדי לפוגע באפשרותם של התובעים למילוט מהמקלט בעתות חירום. כמו כן, אין גם להלום כי זכות זו למילוט תהא תלויה ברצונם הטוב של הנתבעים או בהימצאותם בבית במועד בו, חלילה, יקום הצורך.

73. הנתבע העיד (עמ' 31 שורה 24 לפרוטוקול) כי קיימת נעילת "פרפר" לדלת המצויה בהמשכו של הקיר שנבנה אשר מאפשרת פתיחה קלה למי שיוצא מפתח המילוט. בביקור במקום מצאתי כי אכן קיימת נעילת "פרפר" לדלת זו אשר מאפשרת פתיחה מכיוון המקלט.

74. לאור זאת, אני מורה לנתבעים להותיר בדלת נעילה מסוג "פרפר" המאפשרת פתיחה לכל אחד מכיוון המקלט.

75. כן אני מורה לנתבעים להימנע מהצבת מיטלטלין מכל סוג שהוא בתוואי הדרך שבין חלון המילוט לבין הדלת האמורה. השטח הפנוי יהיה ברוחב שלא יפחת מרוחבו של פתח המילוט ובאופן שלא יגביל פתיחת חלון המקלט או יציאה ממנו.

76. ככל שלא יתקבל היתר בניה לקיר ולקירוי, בתוך שנה מהיום, ייחרסו הקיר והקירוי, הכל כפי שיפורט בפרק "סוף דבר".

המחסן והשטח שנחפר תחתיו-

77. המחסן האמור נבנה מתחת לחניה הצמודה לדירת הנתבעים, אשר סומנה בתשריט יא'. המחסן מודגם בתשריט כשייך לנתבעים ומסומן במספר "2". לאור זאת מדובר בשינויים שביצע הנתבע "בחלקו במגרש".

78. עיון בהסכם השיתוף, מלמד כי הצדדים נתנו האחד למשנהו זכות רחבה ביותר לביצוע שינויים או בנייה בבית, הכוללת: בניה, הריסה חלוקה של היחידה ועוד והכל בכפוף לכל דין.

79. בסעיף 1ה. לכתב האישום המתוקן. מופיע: **"בחזית הצפונית של החלקה, מתחת לחנייה קיימת בנה מחסן בשטח של כ-16 מ"ר ע"י ביצוע עבודות חפירה, יציאת רצפת בטון, פתיחת פתחים לחלונות ודלת, ביצוע עבודות חשמל וגמר."** הנתבע הודה, כאמור, בעובדות כתב האישום, לרבות בבנייה של המחסן ללא היתר והורשע לגביהם.

80. נמצא, אם כן, כי בניית המחסן נעדרת היתר בנייה והיא בניגוד לדין. אמנם המפקח, מר ספקטור, אישר בעדותו כי הנתבע הגיש בקשה לגליזציה לגבי כל העובדות עליהן הורשע בכתב האישום, לרבות לגבי מחסן זה, אך לא נטען וממילא לא הוכח כי כבר התקבל לגביו היתר בנייה כדין.

81. לדידי, אין משמעות לשאלה האם בנית המחסן, כמו גם יתר עבודות הבניה שתוארו לעיל, בוצעו בשנת 2010 או בסמוך לכך, כפי שטוענים התובעים, או בשנת 1995 או בסמוך לכך, כפי שטוענים הנתבעים. עת רכשו התובעים את הדירה חתמו הם על הסכם השיתוף שקבע כי לצדדים לו קיימות אפשרויות בנייה, הריסה, חלוקה וכיוב' רחבות ביותר, **ובלבד** שהללו מבוצעות עפ"י היתר בנייה ובכפוף לכל דין. לאור זאת, בין אם בנייה זו בוצעה ע"י הנתבעים טרם שהתובעים רכשו דירתם, בין לאחריה, משנמצא כי היא בוצעה ללא היתר בניה דינה לשבט. ודוק- לאור דרישתו החד משמעית של ההסכם לקיום היתר בנייה לכל פעולת בנייה שמבצע מי מהשותפים בחלקה, רשאים היו התובעים להסתמך על הוראות הסכם השיתוף, ולהניח כי כל עבודה שביצע או יבצע הנתבע בחלקו המגרש יבוצעו בהתאם להיתר בנייה שניתן. אין להלום כי צריכים היו התובעים במועד הרכישה לגשת לוועדה המקומית על מנת לבדוק אלו עבודות בשטח **שכניהם** נעדרות היתר בניה.

82. הפועל היוצא הוא שככל שהנתבעים יקבלו היתר בנייה למחסן הרי שבנייתו תעלה בקנה אחד עם הוראות הסכם השיתוף, אך ככל שלא יהיו מחויבים להרוס אותו כפי שיפורט בפרק "סוף דבר".

83. דין זה מוצאת אני להחיל גם על שלוש המדרגות המובילות למחסן. בביקור שערכתי במקום התרשמתי כי מדובר על שטח זניח ביותר אשר אינו מהווה הפרעה כלשהי לשטח המשותף, ואשר בניגוד לנטען גם אינו פוגע בזכות המעבר או התמרון של התובעים לחנייה שלהם. להבדיל, הסרתן של מדרגות אלו תמנע אפשרות כניסה לאותו המחסן אשר מצוי בגובה נמוך ממפלס שביל הגישה. משכך, ככל שהמחסן יוכשר ויניתן לגביו היתר בנייה יוכשרו גם המדרגות המובילות אליו. וככל שיהרס המחסן יהרסו גם המדרגות המובילות אליו.

84. באשר לשטח שחפרו הנתבעים מתחת למחסן, בביקור במקום מצאתי כי הנתבעים אכן חפרו את השטח המצוי מתחת למחסן, הוסיפו מדרגות פנימיות באופן שהמחסן הפך לדו מפלסי, וכן פתחו פתחים אל שטח זה.

85. שטח הקרקע מתחת למחסן לא הודגם בתשריט כשטח שבבעלות הנתבעים ומשכך הוא מהווה רכוש משותף, ובעניין זה אין לי אלא להפנות לאמור בסעיפים 51-53 לעיל. הנתבעים לא היו רשאים לחפור שטח זה ללא הסכמת התובעים, ומשכך, גם אם יינתן היתר בנייה לשטח שנחפר לא יהיה בו כדי להכשיר שטח זה ואז את הפתח שפתחו בקיר השטח שנחפר.

86. לאור האמור אני מורה לנתבעים לאטום את השטח שנחפר מתחת למחסן וכן את הפתח שנפתח אליו, בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין, וללא כל קשר לתוצאות בקשת הלגליזציה שהוגשה למחסן.

יתר הטענות-

87. בתביעתם העלו התובעים טענות נוספות ועתרו לסעדים נוספים. ואולם, טענות אלו נזנחו בהמשך ההליך. לא הובאו לגביהם ראיות כלשהן, ולמעט בכתב התביעה לא בא זכרן באף מסמך נוסף, לרבות לא בסיכומי התובעים. בסיכומיהם מפנים התובעים אך לעובדות כתב האישום לגביהן הורשע הנתבע, אלו המפורטות מעלה. בית משפט כבר קבע בעניין זה בעבר כי **"דין טענה שנטענה בכתב הטענות אך לא הועלתה בסיכומים - אם בשל שגגה או במכוון - כדין טענה שנזנחה, ובית המשפט לא ישעה לה"** (ראו: ע"א 447/92 רוט נ' אינטרקונטיננטל קרדיט קורפריישן, פ"ד מט(2) 102, 107 (1995); ע"א 9183/99 פניגשטיין נ' חברת חברי המהפך מס' 1 (מחצבות) בע"מ, פ"ד נח(4) 693, 705-704 (2004); ע"א 172/89 סלע חברה לביטוח בע"מ נ' סולל בונה בע"מ, פ"ד מז(1) 321, 311 (1993)).

88. לאור האמור אני רואה טענות אלו כטענות שנזנחו.

89. ויוטעם, אמנם בכתב האישום נזכרה עבודה נוספת אשר פורטה בסעיף 10. אך בדיון הראשון שהתקיים בתיק נמחק סעד זה מבין הסעדים להם עתרו תובעים.

סוף דבר-

90. אני מורה לנתבעים להרוס את היחידה המערבית ולאטום את השטח שנחפר לצורך הקמתה בתוך שנה מהיום.

91. אני מורה לנתבעים לאטום את השטח שנחפר על ידם מתחת למחסן, ולאטום את הפתח שפתחו אל שטח זה. האיטום יבוצע בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין.

92. באשר לרכיבי הבניה הבאים: היחידה המזרחית, הקיר שנבנה ממזרח לבית, הגגון מקונסטרוקציית עץ, והמחסן. כל רכיב בנייה מבין הללו שלא יתקבל לגביו

היתר בניה, בתוך שנה מיום קבלת פסק הדין, יפעלו הנתבעים להריסתו ולהחזרת המצב לקדמותו בהתאם למצב המודגם בהיתר הבנייה שיהיה בתוקף באותו מועד ביחס לדירת הנתבעים.

93. ויוטעם, כל החיובים בהם חויבו הנתבעים לעיל יחולו עליהם ביחד ולחוד.

94. אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, בהוצאות התובעים, לרבות אגרת משפט, עלות המומחה שמונה ושכ"ט עו"ד בסך של 7,500 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (26.3.15) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כז' בתמוז תשע"ו (2.8.16)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין